

1501308-72.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501308-72.2022.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 8 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr.

FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Matheus de Carvalho Alvarez Teruya, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501308-72.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ALEXANDRO FELIX PEREIRA

Vistos.

JOSÉ ALEXANDRO FÉLIX PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c. 14, II, do Código Penal, porque em 07 de abril de 2022, durante o período noturno, teria tentado subtrair fios elétricos, destruindo o cano de PVC que os acondicionava, sendo interrompido em função da intervenção policial.

A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022 (págs. 45/46).

O réu foi citado (pág. 65) e apresentou defesa prévia (pág. 69).

Certidão contendo o link de acesso à gravação da ação a pág. 126.

Em audiência de instrução, foi coletado o depoimento da testemunha, interrogatório do réu e alegações finais do Ministério Público.

Foi acostado o laudo pericial do local em que foi realizado o furto (págs. 135/140).

Enfim, o réu apresentou suas alegações finais (págs. 144/149).

Era o necessário a relatar.

À fundamentação.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de furto em sua forma qualificada e agravada pelo repouso noturno, de forma tentada, que vem assim previsto no Código Penal:

"Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;"

Consigno, inicialmente, que "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

A pretensão punitiva procede em parte.

A materialidade do delito vem comprovada nestes autos pelo conjunto probatório coligido, especialmente Auto de Exibição e Apreensão de pág. 7, exame pericial do local acostado a págs. 135/140, gravação da ocorrência cujo hiperlink encontra-se a pág. 126, e, enfim, pelos depoimentos coletados.

A autoria recai sobre o réu.

Em audiência, o policial que atendeu a ocorrência afirmou que estava em patrulhamento pelo centro da cidade quando recebeu informação de que foi avisado pelo sistema de monitoramento que tinha alguém mexendo na fiação de uma escola com um alicate. Chegando ao local, encontrou o réu escondido na parte externa da escola, próximo à caixa de energia. Contataram o monitoramento e passaram as imagens gravadas e se certificaram que era mesmo ele que cometia o furto na escola. Ao ser encontrado, o réu aparentava estar sóbrio. Disse que estava descansando. O poste estava danificado e a fiação estava cortada, mas não foi localizado fios retirados. Encontrou no local um alicate e ele tinha uma mala de ferramentas e material de reciclagem. Durante a abordagem não tinha mais ninguém próximo da escola. Afirma que é constante o furto de fiação elétrica no local.

A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TacrímSP - RT 530/372).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas -

Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência."

(HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

Na mesma direção:

"A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (RJTACRIM 48/228).

Ainda:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e outra de multa. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001618-51.2017.8.26.0594; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03 - Sentença condenatória - Recurso defensivo - Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra dos policiais militares - Validade - Precedentes - Réu encontrado na posse da arma de fogo - Condenação mantida - Dosimetria penal - Inobservância do sistema vicariante - Readequação - Necessidade - Reconhecimento da atenuante da confissão - Atenuante da menoridade relativa não restou caracterizada, uma vez que o réu já possuía vinte e um anos na data do fato - Substituição por restritivas de direito - Impeditivo legal - Regime prisional inicial semiaberto - Adequado à espécie - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000420-09.2015.8.26.0542; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)

É de se relevar que todo o descrito pela testemunha está demonstrado visualmente

pela gravação contida nos autos (link a pág. 126), revelando que é o próprio réu o autor do delito, inclusive no momento em que cessou a empreitada criminosa para tentar empreender fuga, sendo abordado pelos policiais logo em seguida da ação. Deste modo, reputa-se que o réu foi preso em flagrante, fato que, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: “Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

Em contraposição, em interrogatório, afirma que estava no local de fato mas os fios já estavam cortados e que somente estava usando drogas e que as ferramentas não eram dele.

Não obstante, diante da robusta prova apresentada, sua palavra carece de credibilidade e não merece aceitação, haja vista que nada do mencionado foi efetivamente gravado pelo sistema de monitoramento, mas tão somente a empreitada criminosa em si.

Diante dessas conclusões, tem-se comprovada, também, a autoria do agente.

Não obstante, não há como considerar a consumação do furto.

Pelo que se atesta, a abordagem ocorreu durante a execução da subtração - embora já cortado parte dos fios em outro ponto, não consta que esses já estivessem completamente removidos (inclusive considerando que ainda eram cerrados durante a intervenção policial).

Em corroboração, vale anotar que não foram apreendidos fios soltos em posse do réu. Desse modo, o crime deve ser reputado como tentado, eis que efetivamente iniciada a ação típica, mas não encerrada, com aquisição e disponibilidade do bem pelo agente. Por fim, como já adiantado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, não é caso de aplicação da causa de aumento pelo fato do furto ter ocorrido em período noturno, considerando o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado pela sistemática de Recursos Repetitivos, de que a referida agravante é incompatível com o furto em sua figura qualificada.

Esse é o Tema Repetitivo 1087 da Egrégia Corte:

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”

Desse modo, afasta-se a referida circunstância da condenação.

Enfim, diversamente do defendido em alegações finais pelo réu, conclui-se bem comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, eis que constatado por perito judicial e descrito no laudo de págs. 135/140, o dano produzido para permitir o acesso à res, não se confundindo com a destruição de parte inerente da coisa, mas sim de obstáculo exterior (tubo que envolvia a fiação) para obstar seu contato e obtenção.

Concluo, pois, que estão evidentes os requisitos concernentes à presença da autoria e da materialidade do delito nas circunstâncias narradas.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Em fundamentação à aplicação das penas, observo que os motivos e circunstâncias do crime não são especialmente reprováveis. A culpabilidade da conduta também já foi mensurada no estabelecimento dos parâmetros abstratos de pena no tipo penal incriminador.

Observando sua folha de antecedentes (págs. 16/27), consta uma condenação em 2011, sem informação quanto ao seu trânsito em julgado para defesa, devendo ser reputado como tecnicamente primário, portanto.

Por outro lado, a consequência do crime é peculiarmente grave. Furtos de fiação elétrica, como o presente, têm se apresentado como problemática constante na região, causando transtornos generalizados na rede de abastecimento de energia e possibilitando causar riscos a eletrodomésticos de cunho essencial, tal qual geladeiras e afins.

E, especialmente considerando se tratar de área próxima a um colégio, tem-se que o furto tinha potencialidade de interromper as aulas por período indistinto, gerando

empecilhos e atrasos a todos seus estudantes em seu ano letivo.

Logo, os danos superam os limites individuais da causa, afetando indistintamente diversas pessoas do local, não podendo ser apenado da mesma forma de quem comete simples furto contra indivíduo único.

Sob esse aspecto, a pena é aumentada em 1/3 na primeira fase, sendo estabelecida em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Não há incidência de causas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena no patamar estabelecido retro.

Enfim, em terceira fase, há de se considerar que o crime não se consumou, devendo sua pena ser reduzida como previsto no artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal.

Conforme descrito pelo laudo a pág. 137, o tubo de acomodação já havia sido rompido e havia interrupção em pelo menos 6 cabos elétricos, mas esses ainda não estava totalmente retirados de seu local de origem.

Assim, em breve divergência ao defendido pelo Ministério Público, tenho que a ação ainda não estava tão próxima à consumação, também não podendo ser considerado como logo iniciada, haja vista que o obstáculo já havia sido removido. Sob essa análise, tenho que ainda estava na metade do curso de sua ação, e, consequentemente, a redução deve se dar em grau mediano, isto é, em 1/2.

Assim, a pena definitiva é estabelecida em 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa

Os dias-multa terão valores mínimos legais, devido à ausência de prova da capacidade econômica do réu.

Dada a quantidade de pena impingida e o fato de as circunstâncias judiciais não serem negativas, o regime inicial de pena será o aberto (artigo 33 do Código Penal e Súmula 440 do C. STJ).

No entanto, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito (§2º do referido dispositivo), consistente em prestação inominada de entrega de uma cesta básica, no valor de um sexto do salário mínimo, em favor de entidade com destinação social a ser indicada na fase de execução da pena e a de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo, de acordo com determinação do juízo da execução.

Dispositivo.

Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para condenar o réu JOSÉ ALEXANDRO FELIX PEREIRA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, inciso I, c/c 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais pagamento de 06 (seis) dias multa, nos valores mínimos legais.

Substituo, com base no artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, a citada pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: prestação inominada consistente na entrega de uma cesta básica, no valor de um sexto do salário mínimo, em favor de entidade com destinação social, e, a prestação de serviços a comunidade pelo prazo indicado supra, respectivamente, a ser indicada na fase de execução da pena.

Por fim, considerando a fixação do regime inicial aberto, de rigor a concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto manter a prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representaria a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele ora estabelecido.

Nesse sentido, destaca-se que, em julgados recentes, o E. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se considerou ser a prisão preventiva incompatível com o regime diverso do fechado em condenação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS

CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185181 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)

HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ADEQUAÇÃO. Ausente demonstração de dedicação do paciente a atividades criminosas, surge adequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTO TÍTULO CONDENATÓRIO REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A previsão do regime semiaberto para o cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se no fechado, implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a do título condenatório. (HC 180016, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020) (grifei)

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade. Violação ao princípio da individualização da pena. Inadmissibilidade. Sistema trifásico devidamente observado em favor do acusado MAICON. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réus confessos. Dosimetria. Pleito de redução da fração de diminuição relativa ao reconhecimento da forma tentada do delito. Possibilidade. Acusados que percorreram iter criminis intermediário. Pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Cabimento. Arma apreendida que estava desmuniada. Ausência de potencial lesivo. Penas redimensionadas. Abrandamento do regime prisional fixado em desfavor dos apelantes. Cabível. Quantum da pena e demais circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime inicial aberto aos acusados MAICON e ÍTALO, e do regime inicial semiaberto ao apelante CARLOS, em razão da reincidência por ele ostentada. Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Revogação da prisão preventiva dos apelantes. Regimes prisionais fixados incompatíveis com a prisão preventiva. Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Recursos parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1500054-83.2021.8.26.0153; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021) (grifei)

Assim sendo, REVOGO a prisão preventiva do réu, autorizando o recurso em liberdade (artigo 387, §1º, do Código Penal). Expeça-se alvará de soltura clausulado. Nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, é o caso de acolher o pedido ministerial de fixação mínima de indenização ao Município-vítima, considerando não somente os danos à fiação, mas a reparação do tubo que a condicionava.

Sem a devida quantificação dos danos, mas tratando-se de patamar mínimo e podendo ser acrescido no caso de comprovação adequada em juízo próprio, estabeleço o valor em meio salário mínimo.

Ao trânsito, providencie o necessário e, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santos, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA